

1500441-88.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... privativa de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ: " (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500441-88.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500441-88.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027195/2022 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 22728564 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2027195 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON MARQUES DA SILVA NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

GERSON MARQUES DA SILVA NETO, com dados qualificativos a fls. 21, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 12h00, na Rua Profeta Esdras, altura do n.º 92, no Jardim Laudissi, próximo a um campo de futebol, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 23 (vinte e duas) porções "crack", com cerca de 1,0 grama, e 06 (seis) porções de cocaína, com cerca de 3,0 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e auto de constatação preliminar de fls. 17/18), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima, para entrega a consumo de terceiros e, na data dos fatos, estava na posse delas nas proximidades de um campo de futebol existente no endereço acima referido.

Ocorreu que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local, quando avistaram o indiciado sentado próximo ao campo de futebol e, como o lugar já era conhecido pela venda de drogas, deliberaram pela abordagem.

Realizada a revista pessoal, em poder do autuado, em suas vestes, encontraram 23 pedras de crack e 06 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 40,00 em espécie e um aparelho celular.

Questionado pelos agentes, GERSON confessou o delito, afirmando que estava ali realizando o tráfico e que, inclusive, o dinheiro era proveniente da venda de drogas realizadas na manhã de hoje. Entretanto, interrogado pela D. Autoridade Policial, assumiu a propriedade das drogas, mas afirmou que as mesmas se destinavam ao seu consumo pessoal.

O acusado foi notificado (fls. 108) e apresentou defesa preliminar (fls. 99/105). A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 114/115) e o réu foi citado (fls. 142). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogado o acusado ao final.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defesa.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, auto de constatação preliminar de fls. 17/18, laudos periciais de fls. 152/154 e 155/160, que constatou ser as substâncias apreendidas cocaína, e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

O policial militar Gabriel Henrique de Campos Gonçalves, disse que, no dia dos fatos, a equipe patrulhava pelo bairro. Na rua em questão há um campo de futebol conhecido pela prática do tráfico. O acusado estava sozinho naquele local, montado numa bicicleta. Havia uma blusa de frio em poder dele. Em revista pessoal nada foi localizado. Na blusa, todavia, acharam 23 porções de crack e 06 pinos de cocaína. O dinheiro estava em notas diversas. Indagado, ele confirmou a prática do tráfico e assim agiu por estar desempregado. Deram voz de prisão em flagrante. Não se recorda de outras abordagens envolvendo o imputado. O réu estava perto da arquibancada. No momento da abordagem ele estava sozinho. Ao ver a viatura, não deu tempo dele reagir. O modus operandi dos traficantes naquela região é igual a do acusado (mídia).

O policial militar Gustavo Aparecido da Silva esclareceu que faziam patrulhamento pela rua, o local é conhecido pelo tráfico. Avistaram o acusado sentado na bicicleta no meio da praça. Conseguiram aborda-lo. Ele estava perto de uma árvore. Com ele não tinha nada. Na blusa, porém, havia quarenta reais, pedras de crack e porções de cocaína. Indagado, ele contou que vendia entorpecentes por estar desempregado. Antes dessa abordagem, ele já havia sido detido pelo mesmo crime em Americana. Não o conhecia até então (mídia).

O acusado, em seu interrogatório, contou que tem 20 anos. Trabalha como ajudante de pedreiro. Foi no bairro em questão, tinha cem reais em dinheiro. Pegou as drogas

para usar. Sobrou dinheiro. Comprou de um rapaz que não sabe o nome. Adquiriu numa rotatória do bairro Romano. O local da abordagem é perto da compra. Estava numa bicicleta. Iria usar toda aquela droga. É usuário. O local da prisão não é perto da sua casa. Costumava comprar entorpecentes naquele local (mídia).

Em que pese a negativa do acusado, estou convencido de que ele estava na posse dos entorpecentes apreendidos para fins de tráfico, pois os relatos dos policiais militares são uníssonos, coerentes, seguros e isentos, não se observando, em nenhum momento, que eles inventarem uma história apenas com o objetivo de prejudicar o acusado.

Inconcebível querer dar guarida à versão isolada do acusado. Para tanto, ter-se-ia que acolher a tese de que policiais procuraram incriminar pessoas inocentes da sociedade, quando lhes conviesse. Esta situação beira o absurdo.

No mais, presume-se que os policiais militares sejam homens sérios, dedicados e fiéis cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de combater a criminalidade local. Para contrapor tal presunção, não bastam meras alegações infundadas; necessária prova concreta e robusta da injustiça da prisão, ou mesmo elementos suficientes que pudessem causar a dúvida no julgador, o que sequer existe nestes autos.

Neste cenário, com tranquilidade reconheço a validade e a importância dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação criminal, pois inexistem elementos para considerá-los indignos.

Nesse sentido, a jurisprudência é farta:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (TJSP, Ap. n. 993.07.105623-5 - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U).

“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado -Recurso defensivo não provido. (TJSP, Ap.n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Camilo Léllis dos Santos Almeida - 05/06/2014).

“TJSP. Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na

modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

O fato do acusado ser usuário de entorpecente não impede que pratique o crime de tráfico de drogas, o qual está devidamente comprovado nestes autos.

E ainda que esteja diante de uma pequena quantidade de droga apreendida, isso não é suficiente para caracterizar, por si só, a condição de mero usuário, quando se tem outros elementos hábeis a comprovar que as drogas se destinavam para fins de tráfico.

Neste sentido:

"A simples alegação de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente em poder do réu, compatível com o uso, não tem o condão de elidir sua responsabilidade pelo crime do artigo 12 da Lei 6368/76, se todo o conjunto probatório está a revelar seu envolvimento no mundo do tráfico" (TJMG) Ap. 000.322.427-7/00 - 2ª Cam - j. 22.05.2003 - Rel. Des. Herculano Rodrigues.

No mais, alegando a condição de usuário, tinha o réu o ônus de comprovar as alegações, nos exatos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal: "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer", mas disso não se desincumbiu, pois nenhuma prova veio aos autos que atestasse a sua condição de usuário de drogas. A esse respeito:

"TÓXICO - Tráfico - Porte de "tijolinho" de maconha - Quantidade suficiente à confecção de oitenta cigarros - Ônus da demonstração de uso próprio pertencente à defesa - Presunção de destinação comercial - Admissibilidade - Recurso parcialmente provido para outro fim. O agente que, na via pública, traz consigo "tijolinho" de maconha, do qual se pode confeccionar cerca de oitenta cigarros, justifica a presunção de tráfico, sendo inadmissível o acolhimento da alegação de uso próprio sem prova cabal e irrefutável nesse sentido, ônus então da defesa". (Relator: Luiz Pantaleão - Apelação Criminal n. 139.646-3 - Araçatuba - 28.06.93)

"TRÁFICO - Tóxico - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimento dos policiais - Credibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 6.368/76 - Inadmissibilidade - Finalidade comercial evidenciada nos autos - Diversidade (maconha e cocaína), quantidade e forma de acondicionamento que respaldam a tipificação - Crime de natureza permanente que caracteriza-se com o simples fato de trazer consigo a droga - Ausência, ademais, de prova da exclusividade de uso próprio - Ônus da defesa - Sentença confirmada - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 290.772-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal "JANEIRO/2000" - Relator: Debatin Cardoso - 20.01.00 - V.U.).

Tem-se, pois, que a quantidade e forma de acondicionamento dos tóxicos, quais seja, porções de cocaína e crack, dinheiro sem comprovação da origem, o local da abordagem e as demais circunstâncias fáticas não permitem a descCLASSIFICAÇÃO para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, restando o quadro probatório firme e robusto, de modo de não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

Sendo assim, a condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e de bons antecedentes. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e neste caso em concreto, o

réu comercializava porções de cocaína e crack, o que vem em seu desfavor, diante da natureza nefasta dos entorpecentes, com grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade. A conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.343/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima: “Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787). Nesse mesmo sentido, têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Por tais razões, aumento a pena base de 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Segunda fase: não há circunstância agravante, porém presente a atenuante da menoridade relativa, de modo que retorno a pena ao seu patamar inicial de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Terceira fase: ausentes causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição de pena, por ser o réu primário (cf. autos nº 1503490-74.2021.8.26.0533 - 2ª Vara Criminal local, com sentença condenatória prolatada em 28/04/2021, impondo a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas alternativas, em grau recursal e sem certificação de trânsito em julgado - E-SAJ), e não se dedicar integralmente às atividades criminosas. Mas o patamar não será pelo máximo, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pela natureza dos entorpecentes apreendidos, pelo que diminuo a pena de 1/3, resultando em 3 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Apesar do entendimento em contrário deste julgador, observo que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, nas duas turmas existentes, que inquéritos policiais ou ações penais sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a afastar o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

A respeito do assunto, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO: FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, HC 170392 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não

constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido". (STF, HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020).

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 4. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 5. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 6. Ré primária. 7. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 8. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 8.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054/SC, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJe 26.2.2015), firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 8.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido". (STF, ARE 1231853 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 17-03-2020 PUBLIC 18-03-2020).

"PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação". (STF, HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020).

Há recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: STJ, HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em 27/07/2012, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. E mais do que isso, no julgamento do HC nº 118533/MS, datado de 23 de junho de 2016, o plenário do STF afastou a natureza hedionda do chamado tráfico privilegiado, sendo plenamente possível fixar outro regime que não o mais rigoroso. E no presente caso, considerando que a primariedade do acusado, mas diante das circunstâncias judiciais não lhe serem totalmente favoráveis, em especial pela natureza nefasta do entorpecente e pelo fato dele estar inserido num contexto organizado de venda de drogas, fixo o regime intermediário para início de cumprimento de pena, o qual se mostra mais eficiente para prevenção e reparação do crime.

Por outro lado, não há como mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a do tráfico ilícito de drogas, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal

diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.

Frente a este panorama, não se pode concluir que regime mais benéfico, neste caso, o aberto, ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos sejam suficientes para o real alcance da pena, que deve servir de fator de retribuição ao agente, de readaptação social e prevenção de novas transgressões. E para o caso do acusado, que estava desempregado e se sustentando através do comércio odioso, procurando obter renda de um jeito mais fácil, o que revela total ausência de responsabilidade e auto disciplina, a substituição por penas mais brandas não lhe é socialmente recomendável. A respeito do incabimento de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ: " (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). Portanto, cometido o crime na sua vigência, indevida a conversão da pena ou a concessão de sursis. 2. Recente entendimento do colendo STF afirma ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, Rel. Min. AYRES DE BRITO); todavia, deve ser ressaltado que foi (a) adotada em sede difusa; (b) por maioria de votos (6x4) e (c) sem efeito vinculante. 3. Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (...). (STJ, HC nº 203.403/ SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, d.j. 21/06/2011).

Nesta fase processual, mantenho a prisão preventiva do acusado, na forma do artigo 387, § único do CPP, para garantir o cumprimento da pena. Foi fixado regime intermediário, e a custódia garante o cumprimento desta, dando-se efetiva aplicação à lei penal.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Preso em razão do flagrante delito, a Lei n.º 11.343/06 veda expressamente a concessão de liberdade provisória para aquele que praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 44). E ainda que assim não fosse, no presente caso se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O crime de tráfico de drogas enseja habitualidade e solto, nada impede que volte a delinquir. E o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo fato novo apontando a conveniência da sua soltura. E a quantidade de pena aplicada e o regime prisional gravoso exigem a custódia cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GERSON MARQUES DA SILVA NETO, qualificado nos autos, às penas de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois proveito do crime em apreço (fls.

40).

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação ds réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da Lei de Drogas.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA